

态。但本案中，某网络技术公司明知双方协议中明确约定未经许可，不得使用对方商标，亦不允许违规架设或与他人合作创建针对普通消费用户的网上商城。且上述约定亦未不正当、不合理地限制或侵害某网络技术公司的合法权益。相反，某电子商务公司对B端和C端客户采取不同的经营策略，以其自主经营方式获利，在满足企业生存和发展需要，不断改善和丰富服务的同时，也为相关合作商提供了不同选择，使不同消费群体可根据自身情况选择相应电商平台。此外，合作商或消费者如不愿接受某电子商务公司所提供的服务模式，亦可转而选择市场中其他相关经营者的服务。故某电子商务公司在本案中通过正当经营，合法竞争获得的利益，应当受到《中华人民共和国反不正当竞争法》所保护。

二、被诉行为是否构成不正当竞争

本案中，某网络技术公司在已向某电子商务公司发函明确整改措施的情况下，本应积极整改，有效避让违反双方合作协议的行为，尽到合理的注意义务。但某网络技术公司依旧通过利用某电子商务公司API接口“暗度陈仓”，擅自将某电子商务商城自营页面内容对接至其自建侵权网上购物商城，利用某电子商务品牌、某电子商务自营、某电子商务物流及供应链的高质量服务向普通消费者直接销售商品，上述侵权行为使某网络技术公司直接省略了其自身品牌建设、招商选品、销售服务、物流配送等必要环节所应付出的时间与资金投入，不正当地取得了某电子商务公司通过长期经营所建立起来的竞争优势，挤占了某电子商务商城及某电子商务E卡的市场份额，违背了诚信原则，扰乱了正常市场竞争秩序，给某电子商务公司造成了较大经济损失。同时，上述侵权行为，易导致消费者误以为自己是从某电子商务公司或者与某电子商务公司有关联关系的企业直接购买了某电子商务自营商品，易导致消费者误以为相关侵权网上商城开办主体以及侵权储值卡销售主体与某电子商务公司之间存在关联或者合作关系，进而导致“某电子商务”品牌商誉的下降，已构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项规定的“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”。

编写人：北京市丰台区人民法院 张炎

APP 名称及标识竞争权益的认定

—— 北京甲信息技术有限公司诉株式会社乙工场等不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京知识产权法院(2022)京73民终2267号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):北京甲信息技术有限公司(以下简称甲公司)

被告(上诉人):株式会社乙工场(以下简称日本乙公司)、乙工场科技(香港)有限公司(以下简称香港乙公司)、北京乙工场科技有限公司(以下简称北京乙公司)

被告(被上诉人):北京丙网络股份有限公司(以下简称丙公司)

【基本案情】

甲公司享有《××A》游戏的著作权。2017年10月31日,甲公司与香港乙公司签署《手游〈3D××A〉独家代理协议》(以下简称《独家代理协议》),授权香港乙公司在日本发行《××A》。在该协议实际履行中,该款游戏由香港乙公司的关联公司日本乙公司对外发行。根据《独家代理协议》约定,《××A》游戏的名称、图标、开机界面(以下合并简称涉案标识)的相关权益归属于甲公司,构成《中华人民共和国反不正当竞争法》所保护的具有一定影响的商品名称、包装装潢。2019年7月,日本乙公司在日本另行发行了一款名为《××A2》的游戏,该游戏在名称、图标、开机界面上与涉案标识相同,并且日本乙

公司宣传该游戏为“国内首个语音在线××A 游戏第2部!添加了新功能!”日本乙公司作为《××A》游戏的发行方还在该游戏中发布下载《××A2》的公告,诱导用户下载《××A2》,上述行为均会使用户混淆《××A2》与《××A》,违反了反不正当竞争法第二条、第六条,损害了甲公司竞争利益。丙公司系《××A2》的开发者,香港乙公司、北京乙公司均参与了《××A》《××A2》的发行,且香港乙公司、北京乙公司与日本乙公司在工作人员、对外宣传、财务管理、业务范围上构成公司人格混同,因此,香港乙公司、北京乙公司、丙公司共同与日本乙公司实施了上述不正当竞争行为,应当与日本乙公司承担连带责任。

【案件焦点】

甲公司主张的混淆行为是否构成不正当竞争。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为:本案中,虽然“××A”名称以及图标最先由日本乙公司在日本申请商标并获得注册,但涉案标识最早使用于甲公司享有著作权的《××A》游戏上。甲公司向市场提供的《××A》游戏服务正是涉案标识指向和发生联系的对象,即涉案标识能够与甲公司提供的《××A》游戏产生对应关系,相关公众能够借助涉案标识区分该游戏与其他游戏。因此,涉案标识的竞争利益应当在尊重其使用过程中与《××A》游戏产生对应关系的基础上归属于甲公司。

《××A2》的游戏名称、游戏图标与开机界面除增加数字2外,与涉案标识在文字、呼叫、字体设计、颜色搭配上基本一致,上述标识本身的近似程度容易导致相关公众对两款游戏来源产生混淆误认。日本乙公司作为《××A》游戏的发行方明知涉案标识最先使用于甲公司的《××A》游戏,但其仍在《××A2》中使用,且《××A2》发行于《××A》尚未下架时,其主观意图难言善意。此外,日本乙公司明知《××A2》与《××A》为两款不同游戏,在《××A2》的应用介绍页面、《××A》游戏中仍以“国内首个语音在线××A 游戏第2部!添加了新功能!”“××A 的新版本将进行内测”的宣传用语刻意突出两款游戏的联系

点；并且，日本乙公司还在《××A》中发布《××A2》的下载地址，用户点击该地址即跳转到《××A2》的下载界面，上述行为足以使相关公众误认为《××A2》为《××A》的升级版本。

日本乙公司被诉不正当竞争行为不当利用了甲公司《××A》游戏的在先商誉，损害了甲公司的竞争利益，应当承担停止侵害、消除影响、赔偿损失的民事责任。

北京乙公司、香港乙公司与日本乙公司共同实施涉案不正当竞争行为，与日本乙公司构成共同侵权，应当承担连带责任。现有证据无法证明丙公司知道或者应当知道甲公司为《××A》开发者的情况下实施涉案行为，故其与三乙公司之间并无共同意思联络，不构成共同侵权，不应与三乙公司承担连带责任。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项、第十一条、第十七条，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零六条之规定，判决如下：

一、被告株式会社乙工场、被告北京乙工场科技有限公司于本判决生效之日起停止在《××A2》游戏中使用“××A”文字、图标、开机界面；

二、被告株式会社乙工场、被告乙工场科技(香港)有限公司、被告北京乙工场科技有限公司于本判决生效之日起三十日内在网站www.×××.jp 首页连续七日刊登声明，消除因涉案不正当竞争行为对原告北京甲信息技术有限公司造成的不良影响；

三、被告株式会社乙工场于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京甲信息技术有限公司经济损失80万元，被告乙工场科技(香港)有限公司、被告北京乙工场科技有限公司在60万元范围内与被告株式会社乙工场承担连带责任；

四、被告株式会社乙工场于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京甲信息技术有限公司合理开支168240元，被告乙工场科技(香港)有限公司、被告北京乙工场科技有限公司在130000元范围内与被告株式会社乙工场承担连带责任；

五、驳回原告北京甲信息技术有限公司的其他诉讼请求。

甲公司、日本乙公司、北京乙公司、香港乙公司不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审法院意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项规定，经营者不得擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。被诉行为是否违反上述规定，应从经营者是否享有涉案标识的竞争利益以及被诉行为是否足以使相关公众混淆误认两方面予以认定。

有一定影响的商品名称是指商品独有的与通用名称有显著区别的名称。本案中，“××A”作为一种游戏服务的名称显然与服务的通用名称“游戏”有显著区别，如果其通过使用具有一定影响，则可以作为《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的主体。装潢是指为识别与美化商品而在商品或者包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。一般而言，装潢在商品外部起到美化作用，相关公众接触游戏软件时首先接触到的是外观图标、开机界面等能够为相关公众直观感知到的部分，进而通过图标、开机界面区分不同的游戏。因此，甲公司主张的图标、开机界面属于《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的装潢。

有一定影响的商品名称、装潢与注册商标专用权获得保护的法律基础不同，注册商标以能够识别商品或服务来源为前提，并不要求其已具有实际的识别作用或者已经实际使用。而有一定影响的商品名称、装潢作为一种未注册商标，其必须经过实际使用并且产生具有识别商品或服务来源的实际意义才能够受到反不正当竞争法的保护，其在经营中产生显著性特征的使用行为是一种事实行为，未注册商标保护的是事实上的正当权益和竞争秩序。因此，其权益归属关键不在于考察哪一主体提出、创造了标识，而应首先考虑未注册商标的使用事实。

未注册商标显著性的产生过程表现为产品或服务提供者的经营行为使其产

品或服务在公众中积累了商誉，因此，未注册商标成为区分不同经营者的标识源于其与特定经营者的商誉之间存在的联系，其为特定经营者商誉的载体。相关公众借助未注册商标才将以特定产品或服务为载体的商誉彼此区分开来。本案中，甲公司提交的若干媒体报道能够证明《××A》游戏在日本市场具有一定的影响力，其提供的游戏质量是其游戏获得市场口碑的重要基础，这也是该款游戏在测试阶段就获得玩家喜爱的重要原因。涉案标识经过使用后使相关公众在看到该标识时联想到《××A》游戏的同时亦会联想到该款游戏的品质、声誉，故此涉案标识不仅起到区分游戏来源的作用，还承载着该标识上的特有利益，涉案标识代表的声誉和品质均源于甲公司提供的《××A》游戏。从上述因素考量，涉案标识的竞争利益应归属于甲公司。

编写人：北京市朝阳区人民法院 田琪雅

比较广告是否构成不正当竞争

——某家居用品股份有限公司诉A（北京）贸易有限公司等侵害商标权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京知识产权法院(2022)京73民终4030号民事判决书

2. 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某家居用品股份有限公司

被告(上诉人): A（北京）贸易有限公司、B 联合科技发展有限公司、C

(北京)科技有限公司(以下简称三被告)

【基本案情】

某家居用品股份有限公司主营X×A 品牌美式家具业务，并在第20类家具商品上取得了“X×B”注册商标。某家居用品股份有限公司品牌具有极高知名度。三被告经营X×C品牌美式家具业务。三被告在门店、网站、微信公众号、微博、展会等多种形式的宣传推广中使用了前述标识，在显著位置注明“X×A 品牌”同款或类似产品的比价信息，宣称“仅为X×A 品牌价格的三分之一”“在选材与质量水平基本一致的情况下，三被告的售价仅是其30%左右”等宣传广告，并宣称X×C 品牌系“市场最高性价比”“产品价格同行业最低”“去掉了不应有的价格泡沫，还原商品本源性价格”。

【案件焦点】

1. 涉案比较广告是否构成虚假宣传或其他不正当竞争行为；2. 涉案“去掉了不应有的价格泡沫，还原商品本源性价格”等宣传语是否构成商业诋毁。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：三被告与某家居用品股份有限公司运营均为美式家具专营品牌，具有直接竞争关系。三被告涉案比较广告未能就比对双方商品的质量、尺寸、原材料、生产工艺、售后服务等情况进行全面展示，亦未考量某家居用品股份有限公司品牌商品可能会因促销活动等发生价格变动的情况，而简单地以显著突出的方式展示双方品牌价格。因市场竞争是一个复杂的、动态的过程，产品销售价格也受成本、市场环境等多方面因素影响，可能存在波动变化。在未明确比对背景，未提供比对依据的情况下，径行使用“市场最高性价比”“产品价格同行业最低”等论断式宣传用语，容易让相关公众产生错误认识。

在对比性广告中，将同类产品进行直接、明显、肯定的优劣对比，必然影响其中被列为较劣一方的产品在公众中的评价，在构成虚假宣传的同时又

可能构成商业诋毁。三被告不是单独对自身价格优势进行宣传，而是在不提及产品生产工艺、原材料、售后服务等其他影响价格重要因素的情况下，通过大量与某家居用品股份有限公司品牌产品的比价广告，突出其价格优势。同时，宣称其价格优势缘由系“去掉了不应有的价格泡沫，还原商品本源性价格”，容易误导相关公众认为某家居用品股份有限公司品牌存在价格虚高、价格泡沫的情形。况且，被告多次将前述宣传语与某家居用品股份有限公司品牌的比价信息进行同时展示，该种宣传方式会直接将上述宣传用语的负面评价指向某家居用品股份有限公司品牌，损害了某家居用品股份有限公司商品声誉，故能够认定为商业诋毁，对于某家居用品股份有限公司该项主张，法院予以支持。

综上，北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条、第六十四条第二款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条、第十一条、第十七条之规定，依据判决如下：

一、被告A（北京）贸易有限公司于本判决生效之日停止侵害涉案注册商标的行为；

二、被告A（北京）贸易有限公司、被告B 联合科技发展有限公司、被告C（北京）科技有限公司于本判决生效之日停止涉案被诉不正当竞争行为；

三、被告A（北京）贸易有限公司于本判决生效之日起十日内就涉案商标侵权行为赔偿某家居用品股份有限公司经济损失20万元；

四、被告A（北京）贸易有限公司、被告B 联合科技发展有限公司、被告C（北京）科技有限公司于本判决生效之日起十日内就涉案不正当竞争行为共同赔偿某家居用品股份有限公司经济损失450万元；

五、被告A（北京）贸易有限公司、被告B 联合科技发展有限公司、被告C（北京）科技有限公司于本判决生效之日起十日内共同赔偿某家居用品股份有限公司维权合理支出10万元；

六、被告A（北京）贸易有限公司、被告B 联合科技发展有限公司、被告C（北京）科技有限公司于本判决生效之日起三十日内在《法治日报》非中缝

位置刊登声明，消除因涉案不正当竞争行为给某家居用品股份有限公司造成的不良影响；

七、驳回某家居用品股份有限公司的其他诉讼请求。

三被告不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

比较广告是通过将己方商品或服务的质量、价格、荣誉、市场数据等相关信息与同类型商品或服务进行对比，以凸显自身商品或服务优势的商业广告。但这种以“比较”为手段为己方争取交易机会的方式，极易误导消费者对“被比较方”产生负面认知，进而损害竞争者利益。本案是一起典型的涉及比较广告是否构成不正当竞争的案件，在适用反不正当竞争法规制比较广告的具体路径、比较广告的不正当性认定两方面具有指引意义。

一、适用反不正当竞争法规制比较广告的具体路径

比较广告类型多样，包括夸大己方、诋毁竞品、以个别要素的差异作为认定优劣的依据、以误导性评测方法比较产品优劣等，竞争行为的复合性、复杂性大幅提高。实践中，权利人一般同时或单独主张适用《中华人民共和国反不正当竞争法》特别条款及一般条款。

就特别条款而言，比较广告将同类商品或服务进行直接、明显的优劣对比，其对比内容、方法均由经营者自行确定，可能出现使用虚假或误导性信息的情况，构成《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的虚假宣传行为；比较广告在说明比对过程和比对结论时，必然影响被评“劣”一方的市场评价，可能构成《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的商业诋毁行为；以比较广告的形式搭便车，与他人产品或服务建立了本不应存在的联系，致使消费者对二者来源或关联关系产生混淆，可能构成《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的仿冒行为。

就一般条款而言，比较广告不能被具体竞争行为条款规制时，如确能认定

比较广告因违反诚实信用原则和公认的商业道德而具有不正当性或者可责性，且经营者的合法权益因比较广告受到实质损害的情况下，可以适用《中华人民共和国反不正当竞争法》一般条款予以调整。

二、比较广告的不正当性认定

比较广告作为重要的市场竞争手段，不应一概予以否定。适用《中华人民共和国反不正当竞争法》规制比较广告行为，应当秉持克制和谦抑的态度，避免因不当扩大反不正当竞争法的规制范围而妨碍竞争自由，抑制市场活力。《中华人民共和国反不正当竞争法》所规制的比较广告，应当具有不正当性。

(一)比较内容是否客观全面

我国法律并不禁止对比广告宣传，但对比广告提供的商品信息应当是全面、客观、充分的。与他人比对应遵守经济伦理、慎言慎行原则，对于数据来源、比较方式、比较基准等信息应当进行注释注解，公开尽量多的相关信息和背景资料，指引受众正确理解。反之可能被认定具有不正当性。

(二)比较方法是否科学中立

要确保比较广告合法正当，还应当注重比较方法的科学中立性。因比较广告系经营者自行发起的比对，比较标准应当引入权威第三方确定的标准，否则必然出现经营者同时成为“比赛”的主办方、运动员、裁判员，比较结果失去规则约束任由经营者自行决定，结果必然失之偏颇，引起消费者不必要的误解。

(三)比较用语是否规范准确

比较广告势必对被评“劣”一方造成市场交易机会受损，商誉贬损的不利后果，故展示比较要素、比较方法、比较结果信息的用语应当规范准确，不得以主观、臆断性语言予以评价，致使被比较者商誉被不合理贬低。

编写人：北京市朝阳区人民法院 谭雅文

四、其 他

58

国家知识产权局在专利无效宣告审查中 可以采纳申请人逾期补充的证据

—— 甲公司诉国家知识产权局发明专利权无效行政案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2023)最高法知行终5号行政判决书

2. 案由：发明专利权无效行政纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 甲公司

被告(被上诉人): 国家知识产权局

第三人(被上诉人): 乙公司

【基本案情】

本专利是国家知识产权局于2016年2月3日授权公告的、专利号为“2013105778xx.1”、名称为“一种铝芯自动扶梯滚轮”的发明专利，其申请日为2013年11月19日，专利权人为甲公司。

2019年11月25日，乙公司向国家知识产权局提出无效宣告请求，请求宣

告本专利全部无效，其理由是本专利权利要求1—6不具备创造性，不符合《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款的规定。乙公司提交了证据1—4。

乙公司于2019年12月26日向国家知识产权局补充提交了证据5和证据6。证据5：公开日为1941年2月4日，公开号为US22307××的美国专利文献的复印件及其相关部分的中文译文。证据6：公开日为1995年7月18日，公开号为US543329××的美国专利文献的复印件及其相关部分的中文译文。

2020年10月30日国家知识产权局举行口头审理，甲公司与乙公司均委托代理人出席了本次口头审理。甲公司表示对证据1—6的真实性和合法性无异议，对证据5和证据6的中文译文的准确性无异议。

国家知识产权局于2021年2月26日作出被诉决定，宣告本专利专利权全部无效。该决定认定：本专利权利要求1相对于证据5与证据6和本领域常规技术手段的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性，不符合《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款的规定。在引用的权利要求1不具备创造性的情况下，从属权利要求2—6也不具备创造性。因此，本专利权利要求1—6均不具备创造性。

【案件焦点】

1. 本专利权利要求1—6是否符合《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款的规定；2. 国家知识产权局作出被诉决定的程序是否违法。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：

关于第一个争议焦点，本专利权利要求1相对于证据5与证据6和本领域常规技术手段的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的创造性。权利要求2—6是权利要求1的从属权利要求，国家知识产权局认为其附加技术特征均属公知常识，其相关认定正确。因此，在权利要求1不具备创造性的情况下，本专利权利要求2—6也不具备创造性。

关于第二个争议焦点,根据《中华人民共和国专利法实施细则》第六十七条规定,请求人逾期补充证据的,国家知识产权局可以不予考虑,而不是不得予以考虑,该法条并未明确禁止国家知识产权局采纳请求人逾期补充的证据。本案中,国家知识产权局在行政程序中采纳了乙公司逾期提交的证据5、6,并未违反法律法规的强制性规定。此外,乙公司仅逾期一天提交证据5、6,甲公司在行政阶段口头审理中已经对证据5、6进行了质证,国家知识产权局出于节约审查成本的考虑采纳证据5、6,在程序上并无明显不当之处。甲公司另主张国家知识产权局认定本专利权利要求2—6的附加技术特征均属公知常识却未进行举证,属于程序违法,该主张缺乏法律依据,法院不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决如下:

驳回原告甲公司的诉讼请求。

甲公司不服一审判决,提起上诉。

最高人民法院同意一审法院裁判意见,判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

国家知识产权局在专利无效宣告审查中是否可以采纳申请人逾期补充的证据?

首先,从法律规定上看,国家知识产权局对于是否采纳专利无效宣告请求中请求人逾期补充的证据具有一定的自由裁量权。《中华人民共和国专利法实施细则》第七十一条规定:“在国务院专利行政部门受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,国务院专利行政部门可以不予考虑。”根据上述法条规定,请求人逾期补充证据的,国家知识产权局可以不予考虑,而不是不得予以考虑,该法条并未明确禁止国家知识产权局采纳请求人逾期补充的证据。《专利审查指南》第四部分第三章第4.3.1条规定:请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,合议组一般不予考虑,但下列

情形除外：(1)针对专利权人提交的反证，请求人在合议组指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；(2)在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。(3)请求人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期。虽然本案乙公司逾期提交的证据5、6并非属于《专利审查指南》规定的“除外”情形，但《专利审查指南》规定的是“一般不予考虑”，也没有明确禁止国家知识产权局采纳请求人逾期补充的证据。

本案甲公司认为，《专利审查指南》上述条款已明确禁止国家知识产权局采纳申请人逾期提交的对比文件，对此，笔者认为，《中华人民共和国专利法实施细则》第六十七条属于行政法规，《专利审查指南》属于规章，行政法规的效力高于规章，作为下位法的《专利审查指南》不得违反作为上位法的《中华人民共和国专利法实施细则》的相关规定。对下位法的解释有不同意见的，应当遵从上位法的明确规定。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第六十七条规定，国家知识产权局对于是否采纳专利无效宣告请求中请求人逾期补充的证据具有一定的自由裁量权。对于《专利审查指南》上述条款的解释应与《中华人民共和国专利法实施细则》第六十七条规定保持一致，不应如甲公司那般作限缩解释。此外，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十四条规定，人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据，人民法院审理行政案件，参照规章。本案中，国家知识产权局可以依据《中华人民共和国专利法实施细则》第六十七条规定采纳乙公司逾期提交的证据。在行政法规已有明确规定的情况下，法院也可以直接依据行政法规作出判决。

其次，从立法目的来看，国家知识产权局“可以不予考虑”或“一般不予考虑”请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的法律规定，其立法目的是限制无效宣告请求人故意拖延程序，督促请求人尽早提交证据，以保

障行政审查程序的高效进行。本案中，乙公司提交证据5、6的时间仅超期一天，无论从主观抑或从客观上看，很难认定其为故意拖延程序的行为。

最后，本案甲公司在行政阶段口头审理中已经对逾期证据5、6进行了质证，其程序性权利并未有任何减损或影响。即使国家知识产权局对逾期证据5、6不予采纳，乙公司仍可以凭借新证据通过另案提起新的无效宣告请求，国家知识产权局出于节约审查成本、为当事人减少诉累考虑采纳证据5、6，并无明显不当之处。

综上所述，国家知识产权局对于是否采纳专利无效宣告请求中请求人逾期补充的证据具有一定的自由裁量权。在请求人未故意拖延审查程序的情况下，国家知识产权局出于节约审查成本的考虑采纳请求人逾期提交的证据，在程序上并无明显不当之处。

编写人：北京知识产权法院 王建宏 庞学硕

未经许可发行故意避开权利人技术措施的 网络游戏外挂程序构成侵犯著作权罪

——何某、王某侵犯著作权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省昆山市人民法院(2021)苏0583刑初969号刑事判决书

2. 案由：侵犯著作权罪

【基本案情】

2018年9月至2021年1月期间，被告人何某、王某等人通过境外聊天软件

与境外“××外挂”运营团队勾连，通过搭建网站，采用比特币交易结算等方式，面向国内外玩家销售针对深圳市某计算机系统有限公司旗下《××A》《××B》游戏的外挂软件，从中获利。被告人何某负责外挂的销售渠道并对接作者团队，被告人王某负责外挂收入的资金结算。仅2020年2月至2021年1月期间，被告人何某、王某通过销售外挂程序各自违法所得分别为1956万余元、978万余元，其间，被告人王某利用违法所得进行投资炒币。被告人何某、王某归案后均如实供述了犯罪事实并自愿认罪认罚。

经某司法鉴定中心鉴定，该外挂软件不存在对游戏客户端数据复制到自身软件中进行修改，并返回修改后的数据给客户端的行为；存在避开某公司专门为游戏采取的MTP(Mobile Threat Protection，旨在检测和防御移动设备上的恶意软件、钓鱼攻击和其他安全威胁)安全保护措施，通过增加修改游戏记载动态库的数量、路径或读写游戏的内存数据等方式，未经授权获取、修改游戏内存数据的行为，以实现“自瞄”“人物透视”“显示物资”等功能，对游戏的正常操作流程和正常运行造成了干扰，属于破坏性程序。

【案件焦点】

何某、王某未经许可发行网络游戏外挂程序是否构成侵犯著作权罪。

【法院裁判要旨】

江苏省昆山市人民法院经审理认为：涉案外挂程序通过破译并擅自使用网络游戏的通信协议，增加修改网络游戏记载动态库的数量、路径、读写游戏的内存数据等方式，未经授权获取、修改《××A》《××B》网络游戏的内存数据，实现网络游戏本不具有的“自瞄”“人物透视”“显示物资”等作弊功能，破坏了网络游戏的正常操作流程和正常运行，损害了网络游戏著作权人的利益、信誉，以及网络游戏的正常市场秩序。何某、王某以营利为目的，未经著作权人许可，伙同他人发行网络游戏外挂程序，违法所得数额巨大，均已构成侵犯著作权罪。在共同犯罪中，何某、王某虽分工不同，但均起主要作用，均系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。何某、王某如实供述犯罪事实，依法予以

从轻处罚。何某、王某自愿认罪认罚，依法从宽处罚。

江苏省昆山市人民法院依照《中华人民共和国刑法》(2017修正)第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款及第二百一十七条第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第二条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》第十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人何某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000万元。

二、被告人王某犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000万元。

三、公安机关查扣的被告人何某、王某的违法所得及孳息，予以没收，上缴国库；不足部分继续予以追缴。

四、公安机关扣押的手机、电脑、比特币钱包等作案工具予以没收；扣押的其他物品由公安机关依法处理。

一审判决后，被告人何某、王某均未上诉，江苏省昆山市人民检察院亦未抗诉。一审判决已发生法律效力。

【法官后语】

随着网络游戏在中国快速发展，制作、销售网络游戏外挂程序的行为日益增多，涉及网络游戏外挂的案件数量不断增长、手段不断更新、形式不断翻新。对于制作、销售网络游戏外挂是否应当予以刑事处罚及适用何种罪名，存在较大争议。本案案件主要争议焦点即在于对被告人何某、王某行为性质的认定及适用罪名问题。

一、制售网络游戏外挂程序的行为不宜认定为非法经营罪

从司法实践来看，不少制作、销售网络游戏外挂程序行为被以非法经营罪追究刑事责任，此种观点主要依据是《最高人民法院关于审理非法出版物刑事

案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《非法出版物解释》)第十一条或者第十五条的规定。《非法出版物解释》第十一条规定:“违反国家规定,出版、印刷、复制、发行本解释第一条至第十条规定以外的其他严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(三)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”第十五条规定:“非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,情节特别严重,构成犯罪的,可以依照刑法第二百二十五条第(三)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”

从条款内容来看,《非法出版物解释》第十一条是对第一条至第十条以外的兜底条款,主要是针对非法经营内容违法的非法出版物的行为,而本案的游戏外挂程序本身并不涉及侮辱、诽谤、淫秽、煽动国家分裂、颠覆国家政权等内容,不属于内容违法的出版物,仅是因非法获取、调用、修改数据即手段违法导致的非法出版物,至多属于程序上违法的出版物,因此不能适用第十一条规定。《非法出版物解释》第十五条的适用条件是严重扰乱市场秩序,情节特别严重,而制作、销售网络游戏外挂程序的行为主要是影响了网络游戏经营者的利益,尚未严重扰乱市场秩序,亦不当适用该规定。

此外,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款明确规定:“非法出版、复制、发行他人作品,侵犯著作权构成犯罪的,按照侵犯著作权罪定罪处罚,不认定为非法经营罪等其他犯罪。”最高人民法院也提出,对于制作、销售网络游戏外挂程序的行为,要全面综合判断行为的社会危害性,秉持刑法的谦抑性,慎用刑事制裁手段。对于社会危险性严重、确需追究刑事责任的制作、销售互联网游戏外挂程序行为,也应妥善选择适用罪名。对制作、销售网络游戏外挂程序的行为应以侵犯著作权罪定罪处罚

年第8期。

。①综上所述，制售本案网络游戏 外挂程序的行为不宜认定为非法经营罪。

①喻海松：《网络外挂罪名适用的困境与转向|经济刑法》，载《政治与法律》2021

